RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.566.844 MINAS GERAIS

RELATORA	**: MIN. CÁRMEN LÚCIA**
RECTE.(S)	: ADELSON GOMES BARBOSA
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório

1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. *a* do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1.0175.17.000071-5/001, "*para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (ad. 65, III, al.* d, *do CP), e compensá-la com a agravante da reincidência (ad. 61, 1 do CP), concretizando a pena imposta a Adelson Gomes Barbosa, pela prática do delito previsto no art. 33,* caput, *da Lei n. 11.343106, em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal*" (fls. 29-30, e-doc. 13). Esta a ementa do acórdão:

> "*APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33,* CAPUT, *DA LEI N. 11.343/06 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 OU PARA A DO ART. 33, §3º, MESMA LEI -*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CE3A-8DE6-BB60-71E5 e senha 1FB2-D992-31FF-ED73

> *INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº11.343/06 - NÃO CABIMENTO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - MANIFESTAÇÃO DO RÉU VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ - COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE VERIFICADA NO CASO DOS AUTOS - FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - NÃO CABIMENTO. - Não basta para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente ou que esta se destinaria ao uso compartilhado, circunstâncias que são perfeitamente compatíveis com o crime de tráfico previsto no ad. 33 da Lei n. 11.343/06. - Para a concessão da benesse prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas, o legislador elencou requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente, quais sejam, o agente deve ser primário, possuidor de bons antecedentes, não pode se dedicar a prática de atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Sendo o réu reincidente, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena. - Se a confissão do réu foi utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida a atenuante prevista no ad. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal. No caso em apreço, é possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. - Diante da reincidência do apelante e do* quantum *de pena aplicado, superior a 04 (quatro) anos, vai mantido o regime inicial semiaberto, previsto na sentença. - A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 anos impede a sua substituição por restritivas de direitos (ad. 44, 1, do CP)*" (fl. 1, e-doc. 13).

A defesa opôs embargos declaratórios para suscitar contrariedade "*no que tange ao reconhecimento da reincidência em desfavor do embargante, ante a condenação anterior nas iras do art. 28, da Lei n. 11.34312006*" (fl. 3, e-doc. 19).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CE3A-8DE6-BB60-71E5 e senha 1FB2-D992-31FF-ED73

Os embargos declaratórios não foram acolhidos pelo Tribunal mineiro (e-doc. 19).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado o inc. X e o *caput* do art. 5º da Constituição da República.

Assevera, "*na dosimetria da pena imposta ao recorrente, que lhe foi aplicada na segunda fase a agravante da reincidência, aumentada a reprimenda. Tem-se, ainda, que a mesma agravante afastou a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas*" (fl. 6, e-doc. 15).

Afirma, "*em análise da CAC acostada aos autos,* (...) *que a reincidência foi gerada através de uma condenação anterior com trânsito em julgado, por porte de substância entorpecente*" (fl. 6, e-doc. 15).

Pede "*seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se o v. acórdão combatido, para, resguardando os dispositivos constitucionais, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343106, com o consequente afastamento,* in casu*, da reincidência reconhecida em desfavor do recorrente e aplicação minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06*" (fl. 12, e-doc. 15).

O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo seja inadmitido e, no mérito, desprovido (e-doc. 23).

3. Depois do sobrestamento dos autos eletrônicos para aguardar o julgamento do Tema 506 por este Supremo Tribunal (e-doc. 25), em 17.7.2025, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Rogério Medeiros, admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 27).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CE3A-8DE6-BB60-71E5 e senha 1FB2-D992-31FF-ED73

4. Em 4.9.2025, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Edson Fachin, determinou a devolução dos autos eletrônicos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral nos termos previstos no art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 30).

5. Em 29.5.2026, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça mineiro, Desembargador Rogério Medeiros, reencaminhou o processo a este Supremo Tribunal, ao fundamento de que "*não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso STF, em razão da dúvida de aplicação ou não da tese firmada em sede de repercussão geral, não havendo, pois, hipótese para a análise da conformidade, no presente caso*" (fl. 7, e-doc. 35).

Em 3.6.2026, os autos eletrônicos foram distribuídos a minha relatoria.

Examinados os elementos havidos nos autos, **DECIDO**.

6. Razão jurídica assiste ao recorrente.

7. Em 6.6.2017, o juízo da Vara Única da comarca de Conceição do Mato Dentro/MG condenou o recorrente às penas de cinco anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de seiscentos dias-multa, pela prática do delito previsto no *caput* do art. 33 da Lei 11.343/2006 c/c inc. I do art. 61 do Código Penal (tráfico de drogas).

Na fixação da pena, o juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência em razão de condenação prévia na Ação Penal n. 2831046-22.2009.8.13.0313, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 9, e-doc. 7).

8. Em 28.8.2018, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro deu parcial provimento ao recurso da defesa apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la com a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CE3A-8DE6-BB60-71E5 e senha 1FB2-D992-31FF-ED73

agravante da reincidência, mantidos os demais termos da sentença condenatória (e-doc. 13).

Sobre a matéria em análise no presente recurso, ficou consignado no julgamento dos embargos declaratórios, ocorrido em 11.12.2018:

> "*No que tange à alegação de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343106, sem razão a defesa do embargante. O Supremo Tribunal Federal, embora tenha reconhecido a questão da (in)constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.34312006 como de repercussão geral, e já tenha iniciado o julgamento (RE 635.659RG/SP), ainda não o concluiu.*
>
> *Destarte, não há que se falar, por ora, em declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.*
>
> *Ademais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, coaduno, por ora, com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal adotado no RE 430.105/RJ, no sentido de que não houve descriminalização da conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos, mas mera despenalização, na medida em que não há no mencionado tipo penal a previsão de pena privativa de liberdade.* (...)
>
> *De fato, não se pode falar em descriminalização do porte de entorpecentes para consumo próprio, já que, a conduta está descrita no Capítulo III da Lei n. 11.343/06, intitulado 'Dos Crimes e das Penas', além do mais, se tivesse ocorrido* abolitio criminis, *não haveria processo, julgamento e consequentemente sanção a ser aplicada. O que realmente ocorreu com a entrada em vigor da nova Lei de Tóxicos foi o* novatio legis in meilius, *ou seja, uma nova lei mais branda, mais favorável que a anterior, retroagindo em benefício do réu.* (...)
>
> *De fato, a norma do art. 28 da Lei de Tóxicos busca o resguardo de bens jurídicos transindividuais, como a saúde e a segurança coletivas, sendo certo que, além do risco à saúde, o consumo de drogas pode fomentar outros delitos, como o tráfico de drogas, bem como delitos contra o patrimônio, sendo patente a necessidade da sua repressão.* (...)
>
> *Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do tipo*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CE3A-8DE6-BB60-71E5 e senha 1FB2-D992-31FF-ED73

> *penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, eis que os bens jurídicos tutelados são a saúde e a segurança coletivas*" (fls. 9-14, e-doc. 19).

9. Ao manter a agravante da reincidência por condenação anterior pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de origem contraria o entendimento recente firmado neste Supremo Tribunal:

> "*AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM* HABEAS CORPUS. *PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ASSENTADA EM ANTERIOR REGISTRO DE INCIDÊNCIA AO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO* DECISIUM. *AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Conquanto não ultimado o julgamento do RE 635.659 (Relator Ministro Gilmar Mendes), que discute a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, revela-se desproporcional considerar condenação anterior pela prática de porte de droga para consumo próprio como causa hábil a configurar reincidência e afastar a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Não se afigura razoável permitir que uma conduta que possui vedação legal quanto à imposição de prisão, a fim de evitar a estigmatização do usuário de drogas, possa dar azo à posterior configuração de reincidência. 4. Além de aparente contrariedade com a própria teleologia da Lei 11.343/2006, no que diz respeito à forma de tratamento que deve ser conferida ao usuário de drogas, deve-se ponderar ainda que a reincidência depende, segundo consolidada jurisprudência desta Corte, da constatação de que houve condenação criminal com trânsito em julgado, o que, em grande parte dos casos de incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006 não ocorre. 5. Cumpre registrar que, nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se a*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CE3A-8DE6-BB60-71E5 e senha 1FB2-D992-31FF-ED73

> *reincidência 'quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior' (grifo nosso). Portanto, o conceito de reincidência reclama a condenação pela prática de um segundo crime após anterior com trânsito em julgado – e não contravenção penal, por exemplo. 6. O art. 28 da Lei 11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na Lei de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem a condão de gerar reincidência, instituto disciplinado no Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido*" (RHC n. 178.512-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.6.2022 - grifos nossos).

Na mesma linha, a seguinte decisão monocrática transitada em julgado proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 886.185/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, processo com controvérsia semelhante à presente:

> *"Dando seguimento ao édito condenatório, registrou a magistrada na dosimetria (eDOC 17): 'Prosseguindo na aplicação da pena, imperioso o reconhecimento da reincidência, cabalmente comprovada (fls. 99), devendo, portanto, a pena-base ser majorada em 1/6, passando para 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, pena esta que torno DEFINITIVA, pela ausência de causas de aumento e diminuição.*
>
> *Deixo de aplicar, na última fase, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, por não preencher o réu os pressupostos subjetivos, pois a reincidência, por si só, inviabiliza sua aplicação.'*
>
> *Observo, assim, que a pena foi agravada, bem como afastado o redutor, com argumento na reincidência do réu.*
>
> *Compulsando os autos, observo que o documento de fl. 99, ao qual se referiu a magistrada para concluir pela reincidência do réu, diz respeito a uma sentença proferida em 11 de junho de 2008. Nesta, o paciente foi condenado como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06 à*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CE3A-8DE6-BB60-71E5 e senha 1FB2-D992-31FF-ED73

pena de advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço a comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, fixando ainda sanção pecuniária. (eDOC 6, p. 20).

Não obstante, a condenação por porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) não gera reincidência. É esse o entendimento desta Corte:

> *AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM* HABEAS CORPUS*. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ASSENTADA EM ANTERIOR REGISTRO DE INCIDÊNCIA AO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO* DECISUM*. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Conquanto não ultimado o julgamento do RE 635.659 (Relator Ministro Gilmar Mendes), que discute a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, revela-se desproporcional considerar condenação anterior pela prática de porte de droga para consumo próprio como causa hábil a configurar reincidência e afastar a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Não se afigura razoável permitir que uma conduta que possui vedação legal quanto à imposição de prisão, a fim de evitar a estigmatização do usuário de drogas, possa dar azo à posterior configuração de reincidência 4. Além de aparente contrariedade com a própria teleologia da Lei 11.343/2006, no que diz respeito à forma de tratamento que deve ser conferida ao usuário de drogas, deve-se ponderar ainda que a reincidência depende, segundo consolidada jurisprudência desta Corte, da constatação de que houve condenação criminal com trânsito em julgado, o que, em grande parte dos casos de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CE3A-8DE6-BB60-71E5 e senha 1FB2-D992-31FF-ED73

> *incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006 não ocorre. 5. Cumpre registrar que, nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência 'quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior' (grifo nosso). Portanto, o conceito de reincidência reclama a condenação pela prática de um segundo crime após anterior com trânsito em julgado – e não contravenção penal, por exemplo. 6. O art. 28 da Lei 11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na Lei de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem a condão de gerar reincidência, instituto disciplinado no Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 178512 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022)*
>
> *A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento de que a condenação de paciente como incurso no art. 28 da Lei de Drogas não caracteriza reincidência. Dessa forma, não é idônea para agravar a pena, tampouco para afastar o redutor, razão pela qual a dosimetria feita na origem, tal como realizada, não pode resistir.*
>
> *Dispositivo: Ante o exposto, concedo a ordem de ofício, para determinar que o juízo de origem refaça a dosimetria, averiguando, inclusive, a possibilidade de aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06"*(DJe 21.3.2023).

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.566.594, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22.9.2025, trânsito em julgado em 16.10.2025; RE n. 1.567.044, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 21.5.2026, trânsito em julgado em 12.6.2026.

10. Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou que "*a atribuição de natureza penal às*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CE3A-8DE6-BB60-71E5 e senha 1FB2-D992-31FF-ED73

sanções cominadas pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas" (RE n. 635.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.9.2024).

Ao fixar a tese de repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal determinou que "*(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta*".

Considerado o julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, sentenças condenatórias fundamentadas no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não conferem repercussão na esfera criminal, **não se justificando a aplicação da agravante de reincidência ao recorrente pela condenação na Ação Penal n. 2831046-22.2009.8.13.0313**, (fl. 9, e-doc. 7).

11. Pelo exposto, **dou provimento ao recurso extraordinário** (als. *a* e *b* do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), **para determinar ao juízo da Vara Única da comarca de Conceição do Mato Dentro/MG (Ação Penal n. 0175.17.71-5) que realize novo cálculo da pena, afastando a utilização de condenações criminais pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343./2006 como agravante da reincidência.**

Oficie-se, de imediato, à Vara Única da comarca de Conceição do Mato Dentro/MG (Ação Penal n. 0175.17.71-5) e ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação criminal n. 1.0175.17.000071-5/001), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CE3A-8DE6-BB60-71E5 e senha 1FB2-D992-31FF-ED73

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 7 de setembro de 2026.

Ministra **CÁRMEN LÚCIA**
Relatora

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CE3A-8DE6-BB60-71E5 e senha 1FB2-D992-31FF-ED73